

1501409-74.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2262247/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20472866 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 5642/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO  
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501409-74.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2262247/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20472866 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 5642/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2262247 - 01º D.P. S.JOSE DO

RIO PRETO, 5642/21/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO LEONOR SOARES

Artigo da Denúncia:

\*

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 24 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de

procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) FERNANDO LEONOR SOARES, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns RAFAEL GONÇALVES PEREIRA e CHARLLINGTON JOSE ARLINDO DA SILVA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, os depoimentos, interrogatórios, e/ou alegações finais foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams", e nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estarão disponíveis o E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à citação do acusado, dando-lhe ciência dos termos da denúncia. Em seguida, procedeu-se à inquirição da(s) testemunha(s) RAFAEL e CHARLLINGTON, bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): FERNANDO LEONOR SOARES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque segundo narra a denúncia, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 09h52min, na Rua General Glicério, 2354, Centro, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros 07 porções de crack, pesando 23,39 gramas (auto de exibição e apreensão às fls. 14/15, laudo de constatação prévia às fls. 20/22 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 128/130), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Conforme restou apurado, no dia e local acima mencionado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina visando coibir o tráfico de drogas em área conhecida pela mercancia espúria, quando avistaram o acusado que, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e tentou fugir. Neste momento foi necessário um breve acompanhamento até que fosse possível a realizar a abordagem na Rua General Glicério, esquina com a Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, defronte ao Clube Palestra. Em revista pessoal, nas mãos do acusado foram localizadas as sete porções de crack, sendo seis pedras inteiras e uma totalmente fragmentada acondicionada em um plástico, além da quantia de R\$ 292,00, e uma pochete na cintura de Fernando que continha mais R\$ 11,85 em moedas variadas. Pela quantidade de droga apreendida, local da abordagem e comportamento do denunciado na ocasião de sua prisão, demonstra-se inequivocamente que o entorpecente apreendido se destinava a comercialização e entrega a terceiros. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão da droga - 07 porções de crack, pesando 23,39 gramas - consoante auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação prévia de fls. 20/22 e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 128/130, com resultado positivo para cocaína, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 do SUS/MS, e atualizações posteriores. A autoria atribuída ao réu na denúncia também restou comprovada. Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls. 5), o acusado confessou a posse da droga, alegando que se destinava a consumo pessoal. Disse que viu um indivíduo desconhecido escondendo a pochete com a droga e quando ele saiu do local subtraiu a pochete com a droga e o dinheiro. A droga era para consumo pessoal. Em Juízo declarou que a droga se destinava a consumo pessoal; é morador de rua e pagou pouco mais de R\$300,00 pela

droga. O policial militar Rafael Gonçalves Pereira, ouvido no auto de prisão em flagrante fls. 2, declarou: "O Depoente afirmou que é Policial Militar e nesta noite encontrava-se com seu companheiro de farda SD PM ARLINDO, em patrulhamento de rotina, momento em que passavam por um lugar conhecido nos meios policiais pela prática da mercancia de entorpecente, sendo que avistaram um indivíduo pela via, e ao visualizar a viatura, demonstrou um certo nervosismo e tentou correr, sendo feito breve acompanhamento e depoente e seu parceiro lograram êxito em abordar o indivíduo na Rua General Glicério, esquina com a Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, mais precisamente de frente ao Clube Palestra Esporte Clube, realizando assim busca pessoal, sendo que eles localizaram nas mãos do indivíduo, 7 pedras de CRACK, sendo 6 pedras inteiras e 1 pedra totalmente fragmentada acondicionada em um plástico, mais a quantia de R\$ 292,00 reais, além de uma pochete que estava na cintura do indivíduo, que em seu interior tinha a quantia R\$ 11,85 reais, em diversas moedas. O indivíduo se apresentou para o depoente com sendo a pessoa de FERNANDO LEONOR SOARES, feito pesquisa via COPOM, não constou como procurado pela justiça. FERNANDO foi questionado pelo depoente sobre o entorpecente e o dinheiro, porém nada quis declarar e nem indicar onde era sua residência, apenas falando que é morador de rua, diante disto, as partes foram conduzidas para este Plantão Policial para as providências cabíveis". Em Juízo, RAFAEL confirmou a mesma versão. O réu, quando foi visto estava a caminho da ponte, onde se comercializa drogas. O réu empreendeu fuga e foi abordado cerca de 50 metros após, defronte do Clube Palestra. O réu tinha 6 pedras brutas de crack bruta e várias fragmentadas, e R\$292,00 na outra mão. A quantidade de droga que o réu portava não é própria de quem apenas usa. O réu estava na situação de "avião", ou seja, ia levar a droga para alguém. O policial militar CHARLLINGTON JOSE ARLINDO DA SILVA, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 4), declarou: "O Depoente afirmou que é Policial Militar e nesta noite encontrava-se com seu parceiro de farda CB PM PEREIRA, em patrulhamento de rotina pela via, sendo que quando passaram por um lugar conhecido nos meios policiais pela prática da venda de entorpecente, avistaram um indivíduo pela via e ao visualizar a viatura, ele demonstrou um certo nervosismo e tentou correr, fora realizado breve acompanhamento, sendo que o depoente e seu parceiro lograram êxito em abordar o indivíduo, mais precisamente na Rua General Glicério, esquina com a Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, ou seja, de frente ao Club Palestra Esporte Club, realizado busca pessoal, foi localizado nas mãos do indivíduo, 7 pedras de CRACK, sendo 6 pedras inteiras e 1 pedra totalmente fragmentada acondicionada em um plástico, mais a quantia de R\$ 292,00 reais, além de uma pochete que estava na cintura do indivíduo, que em seu interior tinha a quantia R\$ 11,85 reais, em diversas moedas. Que o indivíduo apresentou para o Depoente com sendo a pessoa de FERNANDO LEONOR SOARES, feito pesquisa via COPOM, não constou como procurado pela justiça. Quando FERNANDO foi questionado pelo parceiro do depoente sobre o entorpecente e o dinheiro, ele nada quis declarar e nem indicar onde era sua residência, apenas falando que é morador de rua, diante disto, as partes foram conduzidas para este Plantão Policial para as providências cabíveis" Em Juízo, CHARLLINGTON confirmou a mesma versão. Reafirmou que o réu, quando foi visto estava a caminho da ponte, onde se comercializa drogas. O réu empreendeu fuga e foi abordado cerca de 50 metros após, defronte do Clube Palestra. O réu tinha as pedras numa das mãos e R\$292,00 na outra mão. Tudo que estava com o réu não foi apreendido. O réu disse que estava apenas transportando a droga. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. A quantidade de crack apreendida em poder do réu - 7 pedras de crack, pesando 23,39 gramas, o local onde estava - ponto de tráfico de drogas - , a circunstâncias da abordagem o réu estava se dirigindo para a ponte, onde se comercializa droga e o réu, embora tendo uma pochete na cintura, estava com as pedras de crack numa das mãos e quantia de R\$292,00 na outra. Enfim, atitude típica de quem está traficando, ou como disse a primeira testemunha ouvida em juízo, própria de quem estava trabalhando no tráfico como "avião", entregador de droga a terceiros. Além disso o réu apresentou versão no auto de prisão em flagrante, bem diferente da que apresentou nesta data em juízo. Também é certo que o réu é reconhecidamente morador de rua, situação que não se coaduna com a quantidade de droga e dinheiro apreendidos em seu poder.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de drogas a ele imputado na denúncia, a condenação se impõe. O réu registra cinco condenações definitivas, sendo duas por furtos e três por roubos, além de outras condenações pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; portanto, além de reincidente ostenta maus antecedentes e personalidade totalmente voltada para a prática de delitos contra o patrimônio e envolvendo drogas. Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu FERNANDO LEONOR SOARES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a decretação do perdimento definitivo do dinheiro apreendido, produto do narcotráfico, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (Banco do Brasil, ag. 3602-1, conta 170.500-8, código identificador do depósito para o Estado de São Paulo: 110.001-20904-102-6 numerários, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas). Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. FERNANDO LEONOR SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 09h52min, na Rua General Glicério, 2354, Centro, nesta cidade e comarca, o acusado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, 07 porções de crack, pesando 23,390 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Narra a denúncia que policiais realizavam patrulhamento de rotina visando coibir o tráfico de drogas em área conhecida pela mercancia espúria, quando avistaram o acusado que, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e tentou fugir, sendo necessário um breve acompanhamento até que fosse possível sua abordagem, quando, nas mãos do acusado foram localizadas as sete porções de crack, sendo seis pedras inteiras e uma totalmente fragmentada acondicionada em um plástico, além da quantia de R\$ 292,00, e uma pochete, na qual havia mais R\$ 11,85 em moedas variadas. Notificado (fl. 144), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 148). Recebida a denúncia (fls. 151/153), foi citado. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, o acusado foi interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa pediu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado negou a prática do narcotráfico, afirmando ser apenas usuário. Estava fazendo uso de crack quando foi abordado pelos policiais e portava apenas uma pedra de tamanho razoável para seu uso. Também portava uma pochete com dinheiro, não sabendo exatamente a quantia. Esclareceu que conseguiu a droga após ver onde um indivíduo desconhecido escondeu a pochete e, em seguida, se apoderou da pochete que já continha a droga e o dinheiro. Em Juízo o réu novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, dizendo que a droga apreendida se destinava apenas ao próprio consumo e de sua mulher. É morador de rua e usuário de drogas. Pagou em torno de R\$ 300,00 pela droga e havia acabado de comprar. A pochete lhe pertencia e achou no lixo. Estava na fissura para usar a droga que não a guardou na pochete, nem a jogou fora com a abordagem policial.

Os policiais Rafael Gonçalves Pereira e Charllington José Arlindo da Silva, na fase extrajudicial, afirmaram que patrulhavam pelo local, conhecido nos meios policiais pela prática do narcotráfico, onde avistaram o acusado, o qual visualizou a viatura e demonstrou nervosismo, inclusive tentou correr, mas foi abordado. Nas mãos do acusado apreenderam sete pedras de crack, sendo seis pedras inteiras e uma totalmente fragmentada e acondicionada em um plástico, além da quantia de R\$ 292,00, bem como uma pochete que estava na sua cintura, na qual havia R\$ 11,85 em diversas moedas. O acusado nada quis esclarecer, indicando apenas que era morador de rua. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima, qual seja, que o acusado empreendeu fuga em local conhecido como ponto de venda de droga e em seu poder apreenderam as porções de

crack, de tamanho considerável, além de dinheiro. Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação. A materialidade é comprovada pelos documentos de fls.1/17 (auto de prisão), fls.129/130 (laudo) e pela prova oral. De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado, mormente porque a prova dos autos demonstra que o entorpecente apreendido pertencia ao acusado, se destinava ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem. Ressalte-se que os policiais foram incisivos em afirmar que patrulhavam pelo local, conhecido ponto de narcotráfico, e que o acusado, notando a aproximação da viatura, empreendeu fuga, contudo, acabou sendo detido, sendo que em poder dele localizaram as porções de crack e dinheiro. Ressalto que além da droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a forma como estavam embaladas, a tentativa de fuga, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida do acusado, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas. Também não restou comprovada a origem lícita do numerário apreendido. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Anoto que a prova do feito é no sentido de que o acusado tentou evitar a abordagem, empreendendo fuga. Ora, caso não tivesse envolvimento com o ilícito, não teria motivos para fugir. Acrescente-se ainda que o acusado apresentou duas versões. Na polícia disse que achou a droga e o dinheiro e nessa audiência já afirmou que comprou a droga e o dinheiro obteve de forma lícita, perdendo credibilidade a sua versão. Aliás, não foi petrecho para uso da droga, como ele alegou. Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa ao réu, que sequer conheciam. Aliás, como já se decidiu, "Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial" (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180). No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunha policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304). "Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.

Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido" (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018). Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato do réu portar os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, passo à dosimetria das penas. Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do piso, em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, considero o envolvimento do acusado em outros quatro delitos, com reprimendas definitivas (fls. 76, 77/78, 81/82 e 83), configurando maus antecedentes. Considero também a quantidade e a natureza da droga apreendida, crack, droga extremamente nociva, que devasta famílias e contribui sobremaneira com o aumento da criminalidade, dificultando o convívio social. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 78/79), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa, no mínimo a unidade. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado ostenta outras condenações, sendo reincidente, logo, fica afastada a aplicação do redutor. Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedente. 4. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. (...) 7. Habeas corpus não conhecido" (HC 391152/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/04/2017, De 25/04/2017, grifo meu). Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada. Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Além de ser portador de maus antecedentes e reincidente, o acusado foi surpreendido com dinheiro e porções de crack, droga extremamente nociva, que devasta famílias e contribui sobremaneira com o aumento da criminalidade, dificultando o convívio social, confirmando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito

se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeu e a pena a que está submetido, nesta sentença, são suficientes para retratar sua periculosidade se solto, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Ademais, como permaneceu preso durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivesse o direito de deixar a prisão. Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285). O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançou o tempo que lhe permitiria a progressão de regime. Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu FERNANDO LEONOR SOARES como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, no mínimo a unidade. Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal. Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento do numerário apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita do bem apreendido. Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 152). Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Em seguida, o(a) acusado(a) manifestou interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo(a) MM Juiz(a) foi dito que recebia o recurso. Abra-se vista à Defensoria Pública, para o oferecimento das razões de recurso, no prazo legal. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente